

1500903-60.2020.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente 2ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, V. Euclides, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500903-60.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500903-60.2020.8.26.0583 2020/001811

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERNANDO MAGALHAES DE SOUZA, (Alcunha: KINOJO), Brasileiro, Solteiro, Servente, RG 40902972, pai AGNALDO LUIZ DE SOUZA, mãe MARIA TEREZA MAGALHAES DE SOUZA, Nascido/Nascida 01/03/1994, de cor Pardo, natural de Jaboticabal - SP, com endereço à RUA ZEQUINHA DE ABREU, 32, FONE: (18) 9635-1143/99128-8792, JD.

HORIZONTE, CEP 19160-000, Alvares Machado - SP

Advogado

Rogério Schnaider OAB 367820/SP

Juiz de Direito: LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque no dia 16 de dezembro de 2020, por volta de 12h30min, na Rua Francisco Costa de Souza nº 28, Centro, nesta cidade e comarca, LUCAS FERNANDO MAGALHÃES DE SOUZA, qualificado às fls. 04 e 11, estaria guardando, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 08 (oito) porções de "Tetrahydrocannabinol" (maconha), pesando 190,94g (cento e noventa gramas e noventa e quatro centigramas), tratando-se de substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, conforme laudo pericial de fls. 63/65.

O Acusado foi notificado (fl. 105) e apresentou defesa preliminar (fls. 130/138). A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2021 (fls. 144/145), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas

testemunhas de acusação, duas de defesa e após o réu foi interrogado. Por ocasião dos memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 172/177). Por sua vez, a Defesa bateu-se pela absolvição do acusado, por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de posse de droga para uso pessoal. Subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto, substituição por pena restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (fls. 257/269).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 20/21) exames químicos de entorpecente de fls. 22/24 e 66/68, bem como pela prova oral.

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

Em juízo, o policial Valdemir afirmou que os policiais já tinham denúncias de que Lucas fazia o tráfico de maconha naquele local. Viram o réu sentado na calçada e o abordaram. Ao lado de onde o réu estava sentado, encontraram 3 porções de maconha. Na casa do réu, encontraram mais 3 porções grandes de maconha. O réu declinou ser usuário. A própria droga estava espalhada pela casa. Já tinha abordado o réu anteriormente, mas não se recorda quando. As denúncias provinham de usuários, que afirmavam que o réu traficava maconha no muro da residência. O pai do usuário presenciou a busca. No momento, não havia ninguém suspeito próximo ao local. O réu estava sentado do lado de fora da casa, com o portão aberto. Que a droga estava envolta em plástico filme. Afirma que a droga estava pronta para venda.

O policial Angelo prestou depoimento semelhante. Afirmou que nunca abordou o réu. As porções de droga foram encontradas dentro de uma calça jeans no quarto e outra dentro do banheiro, em outra calça jeans. Não foram encontrados outros petrechos de traficância.

Já Maria e Gislaine afirmaram que sabem que Lucas é usuário de drogas há anos. Maria disse que já conversou com o filho sobre isso, lhe reprimindo. Não têm notícias de que Lucas praticava o tráfico de drogas.

O réu, por sua vez, declina que é usuário de drogas e que as drogas eram pra seu uso pessoal. Narra que o dinheiro é proveniente de seu trabalho.

Pois. A prova oral colhida milita em desfavor do réu. Os policiais militares relataram, com clareza e segurança, a dinâmica do dia dos fatos. Ressalto que não há motivo para se duvidar da palavra dos agentes de segurança pública, mormente porque corroborada por outros elementos de prova, e não ficou demonstrada qualquer intenção de prejudicar o réu, vez que este e os policiais não se conheciam previamente ao dia da prisão. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.

PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).

5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).

6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.

8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) (grifei)

Ademais, o réu confessou a posse das drogas, afirmando ser usuário apenas. Não há dúvidas, portanto, a respeito da propriedade, vez que o próprio réu admite serem seus os entorpecentes. No entanto, sua afirmação de que apenas é usuário não encontra amparo nos demais elementos, sendo infirmada pelas evidências que constam dos autos.

As evidências constantes dos autos permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que está presente a materialidade do delito de tráfico de drogas e que a autoria deste delito recai sobre a pessoa do réu.

A Defesa, apesar de seu esforço, não logrou produzir provas que pudessem infirmar a versão acusatória. Em contraponto à acusação, as declarações dos familiares do réu não bastam para que possa se concluir pela sua absolvição ou desclassificação do delito. Deste modo, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória.

Não há que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Veja-se o que prevê o §2º do referido artigo:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, embora não se trate de grande quantidade de drogas, o montante é incompatível com o consumo. Também, o meio de armazenamento (fracionadas para venda) demonstra que se tratava de entorpecente para venda.

Ademais, eventual qualidade de usuário não infirma a qualidade de traficante. As referidas condições não se excluem mutuamente, sendo certo que muitos usuários

realizam a traficância para sustentarem seu vício. Por fim, as denúncias anônimas de usuários de drogas apontavam que o réu realizava a traficância.

Destarte, os supracitados elementos probatórios que constam nos autos demonstram com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação mantida.

Recurso Improvido. (TJ-SP - AC: 15000431420208260598 SP 1500043-14.2020.8.26.0598, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 20/07/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 20/07/2020)

Ainda, outras decisões:

TRÁFICO DE DROGAS - Desclassificação - Impossibilidade - Denúncias de tráfico de drogas - Local conhecido como ponto de tráfico de drogas - Validade dos depoimentos policiais - Credibilidade conferida pelo Estado - Penas bem dosadas - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 30017040320138260079 SP 3001704-03.2013.8.26.0079, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 19/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos, pela prova jurisdicionalizada, a conduta do agente de "ter em depósito" porções de drogas destinadas à disseminação ilegal, impõe-se referendar a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Ademais, a condição de consumidor, invocada para descaracterização do crime de tráfico de drogas, não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, podendo conviver na mesma pessoa as duas circunstâncias: a de traficante e a de dependente químico. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 02284411920158090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 20/02/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2465 de 13/03/2018)

Por fim, conclui-se que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso concreto, a culpabilidade é natural à espécie, não havendo nada que torne a conduta mais reprovável.

Antecedentes criminais: o acusado não possui antecedentes criminais.

Conduta social: não se pode valorar a conduta social do acusado de forma negativa, eis que inexistem elementos suficientes para tanto nos autos.

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique o aumento da pena-base. Logo, deixo de valorar esta circunstância judicial.

Circunstâncias do crime: observa-se que as circunstâncias do crime são normais à espécie. Por isso, deixo de valorar esta circunstância.

Consequências do crime: trata-se de sequelas extraordinárias deixadas pela prática do delito. Não foram constatadas consequências relevantes, motivo pelo qual a pena

não merece aumento.

Comportamento da vítima: trata-se de delitos sem vítima específica.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

c) Causas de aumento e diminuição

O réu faz jus à diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, tendo em vista é primário, de bons antecedentes e não há prova que integre organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa. Ressalto que a quantidade de drogas, por si só, não demonstra que o acusado se dedicava à atividade criminosa.

Tendo em vista que a quantidade não é exacerbada e que o entorpecente possui baixo grau de nocividade, entendo que o redutor deve ser aplicado no máximo legal - 2/3. Fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. À míngua de mais informações a respeito da condição econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido:

TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada, e que o acusado é primário e de bons antecedentes, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Como o condenado preenche os requisitos legais, conforme o artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal - por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo tempo da pena, e limitação de fim de semana (art.43, IV e VI, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções.

Suspensão condicional da pena

Incabível tendo em vista a substituição por PRD.

Manutenção da Liberdade (art. 387, § 1º, do CPP)

O acusado poderá recorrer da sentença em liberdade.

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do Funad, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2006, p. 822):

"O artigo 63, caput, fuge, de certo modo, à regra do art. 91 do Código Penal.

Quando algo é apreendido ou sequestrado, por ser instrumento ou produto do crime, proferida sentença condenatória, automaticamente, considera-se confiscado o bem (ou conjunto de bens). (...) Pensamos que a melhor interpretação é seguinte: a) se as coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime,

estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na sentença condenatória (...)." (destaquei)

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, a ser revertido ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal e o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR LUCAS FERNANDO MAGALHÃES DE SOUZA já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada qual fixado no valor de 1/30 do salário mínimo e atualizado monetariamente desde a época do fato, sendo a pena substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo tempo da pena, e limitação de fim de semana (art.43, IV e VI, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções.

Intime-se o réu, por meio de mandado, devendo ele ser indagado sobre o interesse de recorrer desta sentença, lavrando-se termo positivo ou negativo, conforme o caso. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade.

Expeça-se o que mais necessário.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Presidente Prudente, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA